

1501056-26.2021.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... que receberam informação de ocorrência de tráfico de drogas, na região do Poupatempo. Através de trabalho de campo, percebeu que Johnas mantinha encontros com pessoas conhecidas pelo tráfico. Nesses encontros, Johnas pegava sacolas de grande volume. A maioria dos encontros se dava no horário de almoço. A equipe policial estava prestes a solicitar mandado de busca e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501056-26.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501056-26.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2260960/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 20448000 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 87/21/567 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2260960 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOHNAS MENEGUEL GIMENES ANDRE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

JOHNAS MENEGUEL GIMENES ANDRE, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, o acusado, no dia 23 de setembro de 2021, por volta de 14h, na Rua Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, número 2-59, Bairro Vila Seabra, nesta cidade de Bauru-SP, mantinha em depósito 22 tijolos de maconha, para fins de tráfico.

Auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial (fls. 14/17), laudo definitivo (fls.

97/101).

Às fls. 108/110, foi determinada a notificação do réu para que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06, oferecesse defesa prévia, por escrito, no prazo de dez dias. Na mesma oportunidade, a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021.

O acusado foi notificado (fls. 86) e apresentou defesa prévia (fls.90).

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, realizada em 11 de fevereiro de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas comuns e de defesa. O réu foi interrogado (fls. 198/200).

A Douta Defesa juntou documentos (fls. 202/216).

Em sede de memoriais, o Ministério Público pediu, em resumo, a procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu. Asseverou que os policiais civis André e Valéria confirmaram os fatos. Apontou que o acusado negou a traficância. Sustentou que corroboram a condenação: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 14/17), laudo pericial (fls. 97/101) e relatório final (fls. 102/104). Entendeu que a autoria e materialidade foram demonstradas. Pontuou que são válidos os depoimentos dos policiais. Pediu a condenação do acusado. Acrescentou que o réu é reincidente específico. Argumentou ser inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Sugeriu a pena de 08 anos de reclusão e pagamento de multa, em regime fechado (fls. 221/228).

A Defesa, por sua vez, explicou que o acusado é pessoa jovem e possui família, bem como trabalhava como auxiliar de mecânico. Destacou que o réu confessou os fatos. Mencionou que o réu guardou as drogas para quitar uma dívida e está arrependido. Destacou que o réu não era conhecido no meio policial. Requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Enalteceu que condenações criminais não podem ser consideradas como Maus antecedentes quando ultrapassado o período depurador de cinco anos. Pugnou pela consideração do período de seis meses que o réu permaneceu custodiado (detração penal). Requereu o direito de o réu apelar em liberdade (fls. 232/241).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo pericial (fls. 14/17), laudo definitivo (fls. 97/101).

Quanto à autoria, é certa.

Vejamos.

Em juízo, a testemunha policial civil André Luis Mustafá disse, em suma, que receberam informação de ocorrência de tráfico de drogas, na região do Poupatempo. Através de trabalho de campo, percebeu que Johnas mantinha encontros com pessoas conhecidas pelo tráfico. Nesses encontros, Johnas pegava sacolas de grande volume. A maioria dos encontros se dava no horário de almoço. A equipe policial estava prestes a solicitar mandado de busca e apreensão na residência do réu. Não conseguiram coletar imagens ou abordar o acusado Johnas, pois a investigação era feita de forma discreta, com reduzido número de policiais. Conseguiram se agrupar no local com número maior de policiais, em horário de almoço. Depois de 40 minutos

de observação, avistaram que o Johnas saiu de sua residência na posse de sacola de grande volume. Decidiram abordá-lo. O réu tentou se evadir, mas foi detido. Na sacola, havia em torno de 10 pinos de maconha. O réu franqueou a entrada dos policiais na residência. Encontraram 10 quilogramas e balança de precisão. A pessoa que compraria as drogas não foi identificada. Disse que estão investigando, ainda, os fornecedores dos entorpecentes. Pessoas que auxiliavam os policiais, informalmente, noticiaram sobre o tráfico de drogas. Essas pessoas preferem ajudar de modo informal, sem serem qualificadas. Não atuam apenas com base nessas informações. O réu residia num imóvel onde uma garagem é usada como oficina. A entrega das drogas era feita na região do Poupatempo. O réu saía com as sacolas e permanecia naquela região. Nunca viram o réu no exercício de atividade lícita. Viram o réu em contato com pessoas que tinham envolvimento com a criminalidade. Nos acompanhamentos, estava sozinho ou em poucos policiais, por isso, não abordou o acusado antes. No dia da abordagem, o réu tentou se evadir. Encontraram drogas na sacola, em primeiro lugar. No imóvel, apreenderam mais dez quilogramas de drogas. O réu confessou o tráfico de drogas. Na residência, havia "pessoas de bem", por isso o acusado confessou, desde logo. As drogas estavam no guarda-roupa dele. Acredita que os familiares não tinham ciência do envolvimento do réu com o tráfico. Os familiares do réu são "pessoas de bem". O réu tinha alguns antecedentes pela Polícia. O réu mencionou que trabalhava numa oficina, situada na residência do acusado. A genitora do réu e o padrasto dele eram "pessoas de bem". O réu se aproveitou da confiança dos seus familiares para praticar o tráfico de drogas (fls. 198/200).

Em juízo, a testemunha policial civil Valéria Isabel dos Santos, de forma abreviada, narrou que receberam informação de que um indivíduo praticava tráfico de drogas, na região do Poupatempo. Viu Johnas, o qual fazia movimentações condizentes com a traficância, recebia e entregava algo para pessoas. Estavam em poucos policiais, motivo pelo qual não abordaram o réu naquele momento. No dia dos fatos, estavam com uma equipe com maior número de policiais. Viram que o réu saiu da residência, em posse de uma sacola grande. O réu tentou se evadir. Na sacola, havia dez quilogramas de drogas, em tijolos de maconha. Na residência, encontraram outros tijolos de maconha no guarda-roupa e balança de precisão. Conseguiram colher as digitais nos tabletes de maconha. A perícia averiguou que as digitais eram do acusado. Muitas pessoas apareciam na delegacia, pediam sigilo e relatavam sobre o comércio espúrio. As drogas (tabletes) estavam numa mochila. No imóvel, estavam presentes a esposa do réu, a genitora dele e o padrasto. No quintal do imóvel, havia peças de veículo. O réu disse que chegou a trabalhar no local como mecânico. Não conhecia o réu do meio policial. Os familiares do acusado ficaram "assustados" e comentaram que o réu tinha acesso ao imóvel todos os dias. O imóvel não era uma "biqueira" (fls. 198/200).

Em juízo, a testemunha de defesa Thiago José Chiari de Souza, em resumo, contou que é cliente da oficina mecânica pertencente aos familiares do acusado. Soube dos fatos, através da genitora do acusado e por notícia veiculada em jornal. O réu era ajudante na oficina e sempre o atendeu bem. O acusado era "bom pai e uma boa pessoa". Nunca presenciou o acusado em posse de drogas. A oficina era de reparos em motocicleta. O acusado trabalhava com o padrasto, com troca de acessórios. Não sabe se o acusado já foi preso anteriormente (fls. 198/200).

Em juízo, a testemunha de defesa Mariane Raquel da Cunha, em resumo, falou que o réu era um "bom pai e esposo". A esposa do acusado é sua cliente. A esposa do réu sempre falou bem do acusado e nunca mencionou que o acusado fosse envolvido com drogas. Sabe que o réu tem antecedente criminal (fls. 198/200).

Em juízo, a testemunha de defesa Maycon Henrique dos Santos contou, em suma, que o réu trabalha como ajudante geral da loja dos genitores dele. Faz dois anos que trabalha no mesmo local e vê o acusado. O réu trabalha numa oficina (fls. 198/200).

Em juízo, a testemunha de defesa Beatriz Nascimento dos Santos, em suma, asseverou que é cunhada do acusado. O réu já teve "problemas com a Justiça", mas já foi resolvido. O acusado trabalhava numa oficina com o genitor dele. O réu é excelente "pai" e marido. O réu tem bom comportamento. Johnas não residia no imóvel onde foi preso. O réu residia com sua irmã, no bairro Santa Edwirges. O filho do Johnas passou mal e foi ao médico. Os filhos dos réus têm três e cinco anos. O filho de três anos teve que passar pelo médico (fls. 198/200).

No interrogatório judicial, o réu Johnas Meneguel Gimenes André, em resumo, afirmou que guardou as drogas. Estava há cinco dias na residência de sua genitora, pois tinha discutido com sua esposa. No quarto dia, recebeu a proposta de guardar entorpecentes. Tinha dívidas de R\$ 1.000,00. Ofereceram-lhe R\$ 1.500,00 para guardar as drogas. Está arrependido de ter adotado essa conduta. Tem dois filhos. Sempre foi um bom pai. É auxiliar de mecânico. Tem 28 anos. A oficina onde trabalhava fica situada na Rua Araújo Leite. "Paraná Auto Peças" tem 20 anos. Seu filho Brian sente sua falta. Está muito arrependido. Auferia renda de R\$ 1.000,00 na oficina. Sua genitora pagava salário e o ajudava muito (fls. 198/200).

Compulsando os autos, denota-se que a autoria e materialidade foram demonstradas. Com efeito, os policiais civis André e Valéria prestaram depoimentos harmônicos, no sentido de que receberam uma "denúncia anônima" que relatava que um indivíduo exercia o comércio espúrio, nas proximidades do Poupatempo. Diante dessas informações, fizeram diversas observações pela localidade. Durante as campanhas, os policiais viram o réu Johnas em contato com pessoas envolvidas com a criminalidade, bem como fazia gestos típicos da traficância, como a entrega de objetos a pessoas, na via pública. Acrescentaram os policiais que, no dia da abordagem policial, a equipe notou que o réu saiu de sua residência na posse de uma sacola de grande volume. Este, ao perceber que seria abordado, tentou empreender fuga, mas foi detido pelos agentes de segurança. As testemunhas encontraram entorpecentes no interior dessa sacola. Ato contínuo, o acusado franqueou a entrada dos policiais em sua moradia, onde, em seu quarto, havia mais tijolos de maconha e uma balança de precisão.

Sobre a validade dos depoimentos policiais, em crime de tráfico de drogas, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou:

Apelação Criminal- Tráfico de Drogas- Recurso Defensivo- Direito de recorrer em liberdade Prejudicado pelo efetivo julgamento do presente apelo. Absolvição por insuficiência probatória Impossibilidade - Afastamento ou redução da pena de multa - Inviabilidade Condenação mantida - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais Responsabilização inevitável Legalidade e compatibilidade evidenciadas Conjunto probatório seguro e coeso - Traficância caracterizada Condenação de rigor Réu reincidente - Redutor Impossibilidade de aplicação Penas bem dosadas Regime inicial fechado necessário à reprovação e prevenção do crime De rigor a decretação do perdimento dos valores - Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP - Apelação Criminal 1501009-30.2020.8.26.0548, Relator(a): José Vitor Teixeira de Freitas, Comarca: Campinas, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 28/02/2022, Data de publicação: 28/02/2022).

Nessa senda, vale destacar que não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Isso porque, em primeiro lugar, o réu foi visto pelos policiais civis em gestos de mercancia ilícita e em contato com pessoas ligadas à criminalidade. Ademais, não se pode olvidar o comportamento do acusado, o qual, sem motivo plausível, tentou se evadir dos policiais civis. Isso sem falar, ainda, que além dos entorpecentes, na residência do acusado, foi apreendida uma balança de precisão.

De mais a mais, além da robusta prova testemunhal, tem-se que o próprio acusado, em

juízo, admitiu que guardou os entorpecentes na sua residência, para quitar uma dívida com outros traficantes e, em troca, receberia a quantia de R\$ 1.500,00. Sendo assim, é de rigor a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Sendo assim, não obstante a nobre Defesa ter comprovado que o réu exercia atividade lícita em oficina mecânica, tal fato, por si só, não exclui a conduta ilícita de ter guardado drogas em sua residência. Além disso, os policiais foram unânimes no sentido de que também viram o réu fazendo gestos de mercancia ilícita. Logo, não há elementos que afastem a ilicitude do fato ou a culpabilidade do agente.

Assim, não resta dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva, sendo evidente que a conduta do réu se enquadra no tipo penal previsto no artigo 33, da lei federal n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Passo à fixação da pena.

Atenta ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do artigo 59, do CP, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, eis que o réu registra antecedentes criminais (fls. 34 - Processo 0006848-33.2013.8.26.0071 - fato ocorrido em 27/02/2013; fls. 34 - Processo 0009260-68.2012.8.26.0071 - fato ocorrido em 05/03/2012). Nessa senda, com todo respeito a nobre e combativa defesa, não há que se falar em afastamento desta circunstância sob a égide de que já ultrapassou o período depurador de cinco anos. Isso porque o STJ já entendeu que o lapso temporal de cinco anos não tem o condão de descaracterizar o "antecedente criminal", diferentemente da reincidência. Nesse sentido:

"2. De acordo com a jurisprudência desta Eg. Corte, condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes. 3. No caso, o agravante possui maus antecedentes, razão pela qual, acertadamente, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal e afastada a incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas" (AgRg no Ag no REsp 1.864.887/SP, Quinta Turma, j. 23/06/2020).

"Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações pretéritas com trânsito em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes" (AgRg no REsp 1.819.128/SP, Sexta Turma, j. 30/06/2020).

Outrossim, verifica-se que as circunstâncias nas quais o crime foi cometido são desfavoráveis, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado (13.042,92 gramas - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13), as quais, certamente, seriam destinadas a um número indeterminado de usuários. Sendo assim, a aplicação da reprimenda penal em face do réu deve levar em conta a severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública e em patamar que desestime novas condutas semelhantes, por parte dele e de outros membros da sociedade. Além disso, a Jurisprudência Paulista já entendeu que "aquele que se dedica à espúria difusão do vício em droga de tamanha nocividade, em tese, demonstra personalidade malformada, sem a mínima sensibilidade social", o que justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. Nesse sentido:

"Na primeira fase, atento aos ditames do artigo 59, "caput", do Código Penal, e do artigo 42 da Lei de Drogas, o MM. Juízo "a quo", sopesando negativamente as

circunstâncias judiciais, em especial, a grande quantidade, nocividade e diversidade das drogas apreendidas (58 porções de “maconha”, com peso líquido de 137,9g, 134 porções de “cocaína”, com peso líquido de 86,2g, e 32 porções de “crack”, com peso líquido de 5,5g), - de grande poder destrutivo e alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública, e de aptidão letal, fixou a pena-base, acrescida de um sexto (1/6), em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal. O crime de que se cuida tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie, porquanto, a nocividade, variedade e elevada quantidade da droga apreendida, alcançando número maior de usuários com predileções específicas, demonstram dolo intenso com que se deu o réu. Convém sublinhar que: “A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefasta mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154), in HC nº 2023748-42.2014.8.26.0000 1ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes -, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel.: Exmo. Des. TOLOZA NETO, em 13.05.2014). Aquele que se dedica à espúria difusão do vício em droga de tamanha nocividade, em tese, demonstra personalidade malformada, sem a mínima sensibilidade social. Nesse sentido: “A infração atribuída ao increpado é demolidora da integridade moral e mental de seus desditosos alvos; submete progressivamente os incautos ao cativo existencial do vício morfético e ao mais deletério ócio, porque os vitimados por essa chaga praticamente conduzem sua vida produtiva ao epílogo” (Habeas Corpus nº 2049710-67.2014.8.26.0000 Comarca de Mogi das Cruzes, Colenda 3ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Exmo. Des. GERALDO WOHLERS). Não se olvide, que o “legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado” (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017). Desse modo, por não se entender desarrazoado o aumento da penabase, ante as justificativas expostas na r. sentença, fica mantida a pena-base como lançada. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, as penas foram mantidas como fixadas na fase anterior. Nesse ponto, não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Nesse sentido, “espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito” (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. “Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade”. (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169). Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se a pena definitiva tal como fixada na fase anterior. Destaca-se que a aplicação da

causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, restou vedada por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Como se constata, o paciente, para além de ter capacidade moral para delinquir, dedica-se à difusão espúria de drogas proibidas aliás, de grande poder destrutivo, com animus lucrandi, de maneira profissionalizada, própria de quem é estabelecido no ramo do crime, fazendo do tráfico de drogas *modus vivendi*. Não bastasse, o paciente foi pilhado em situação flagrancial, em lugar conhecido como ponto de venda de drogas, mercantilizando e trazendo consigo considerável quantidade e diversidade de drogas (58 porções de “maconha”, com peso líquido de 137,9g, 134 porções de “cocaína”, com peso líquido de 86,2g, e 32 porções de “crack”, com peso líquido de 5,5g), com potencial para atingir grande quantidade de usuários. O lugar do crime é conhecido ponto de comércio nefasto de drogas proibidas e o acusado mercantilizava, de maneira aberta, em plena luz do dia as drogas. Pela pertinência e lucidez, obrigatória a transcrição de parte do respeitável julgado em que foi Relatora a Excelentíssima Doutora Ivana David: “(...) Em que pese a primariedade do réu, restou acertada a não aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto, (...) o local conhecido como “ponto de venda de drogas”, além do depoimento da testemunha (...) relevam que o réu se dedicava à atividade criminosa. Por outro lado, ainda que não se tenha provas exatas sobre a qual organização criminosa pertença o acusado, é certo que para vender drogas em um conhecido “ponto de vendas de entorpecentes” ele deve, necessariamente, estar inserido na estrutura da organização criminosa estabelecida naquela região, uma vez que, ainda, não há “livre concorrência” na venda de drogas. Ora, seria leviano acreditar que o réu simplesmente comprou papelotes de drogas em outro ponto de tráfico, escolheu aquele local, coincidentemente, já conhecido pela venda de entorpecentes, e iniciou o seu “negócio”. Tal conclusão não se trata de suposição ou mera conjectura, pois é de conhecimento público e notório, notícias divulgadas diariamente pela imprensa, a disputa de pontos de venda de drogas entre organizações criminosas rivais. Assim, é certo que (...) se dedicava às atividades criminosas de tráfico de drogas, bem como há indícios de que integra organização criminosa, sendo impossível a concessão do redutor, previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. (Ap. nº 0004998-62.2011.8.26.0604 - Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Exma. Dra. IVANA DAVID). Ainda, para ilustrar a inviabilidade de causa de diminuição de pena: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In casu, tratase de apreensão de 54 pedras de crack - “50 embaladas de dez em dez e quatro avulsas” -, circunstância esta que impede a aplicação do mencionado redutor de pena. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp: 1302590 RS 2012/0016349-7, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, j 11/03/2014, Colenda SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2014). A benesse sob comento trata da figura do “traficante privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, estabelecendo a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, incabível, no presente caso, a aplicação da benesse pretendida. Por fim, devidamente eleito o regime inicial fechado para cumprimento da pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, assemelhado ao hediondo, na forma da Lei nº 11.464/2007, independentemente da quantidade de pena fixada” (TJSP - Apelação Criminal nº 1501404-12.2021.8.26.0540, Relator(a): Freddy Lourenço Ruiz Costa, Comarca: Mauá, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 22/02/2022, Data de publicação: 22/02/2022).

Dessa feita, fixo a pena base elevada em 1/3, ou seja, 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Sendo assim, reduzo a pena em 1/6, o que resulta em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 555 dias-multa.

Ademais, nesta fase, cabe destacar que é inviável a agravante do art. 61, II, 'j', do CP, tendo em vista que não foi comprovado, nos autos, que o réu se valeu da situação pandêmica para praticar o delito em tela, conforme entendimento majoritário atual da nobre Corte Paulista, o que implicou em revisão de posicionamento anterior deste juízo monocrático.

Na última fase, justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as circunstâncias da prática delitiva, demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio ilícito de drogas. Demais disso, vale destacar que a apreensão de grande quantidade de drogas em poder do acusado é incompatível com a figura do "traficante de primeira viagem". Isso sem falar que o réu possui condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime análogo (fls. 34 - Processo 0006848-33.2013.8.2660071).

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre as situações econômico-financeira favoráveis do réu.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente fechado, diante da quantidade de pena aplicada, da quantidade, natureza da droga encontrada e das condições em que ocorreu o crime, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização do réu totalmente imerso no mundo da traficância.

Nessa toada, com todo respeito à nobre e combativa defesa, não há que se falar, neste momento processual, no reconhecimento do tempo da prisão preventiva para a fixação do regime inicial da pena (detração penal). Com efeito, vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo entende que a detração penal deve ser melhor avaliada pelo juízo da execução penal. Nessa linha:

"Apelação. Tráfico de Drogas - (Artigo 33, "caput", da Lei 11343/06) - Preliminar da defesa pela anulação do processo em razão da ausência de citação - Inocorrência - Réu devidamente notificado, nos termos do art. 55 da Lei 11343/06 - Ausência de prejuízo - Preliminar da defesa pela nulidade da instrução e da sentença pela decretação da revelia - Não cabimento - Preliminares afastadas - No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11343/06 com a subsequente absolvição pela atipicidade material da conduta, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal ou com a declaração de nulidade do feito por incompetência - Inviabilidade - Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Não cabimento - Detração Penal - Inviabilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras das testemunhas - Responsabilização inevitável - Legalidade e compatibilidade evidenciadas - Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido. Embora não se desconheça o teor do artigo 387, § segundo, do Código de Processo Penal, não há se cogitar de sua aplicação imediata nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos do comportamento do réu no cárcere e do efetivo lapso que permaneceu preso, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções, evitando-se, ainda,

supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, o artigo 42, do Código Penal, trata da detração para fins de pena e, inegavelmente, tem como órgão competente o Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP). O pressuposto de validade processual repousa perante o Juízo das Execuções, porquanto a matéria atinente à detração não comporta discussão no processo de conhecimento, devendo a questão ser analisada quando da execução do julgado, consoante se infere do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, regra não contrariada pela alteração legislativa promovida pela Lei Federal 12736/2012. Assim: "APELAÇÃO. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. APRECIACÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Restando demonstrado pelo robusto conjunto probatório que o apelante portava, sem autorização legal ou regulamentar, a arma de fogo de uso restrito e as munições apreendidas, incensurável se mostra a solução condenatória proferida. Ademais, nenhum reparo merece a sentença no que tange à aplicação da detração penal. O legislador inseriu o § segundo, no artigo 387, do CPP, por meio da Lei 12736/12, dispondo que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo ele, portanto, o competente para a apreciação do referido pleito, consoante o preceituado no artigo 112 da Lei 7210/84. Desprovemento do recurso" (TJRJ - Apelação 0400285-32.2014.8.19.0001 - Relator: Des. Antonio Eduardo Ferreira Duarte - Data de Julgamento: 13/10/2015 - Data de Publicação: 19/10/2015) E, apesar de a Lei Federal 12736/2012 ter acrescentado o § segundo ao artigo 387, do CPP, determinando que o Juiz da condenação deva considerar a detração quando proferir a sentença, não revogou o artigo 66, da Lei de Execução Penal, que atribui ao Juízo da Execução a competência para deliberar sobre a detração, sendo ele o mais indicado. Diante disso, o pleito de detração deverá ser formulado perante o Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais, a teor do que dispõe artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei Federal 7210/84. Portanto, não há que se falar em ofensa a qualquer dos princípios e normas constitucionais, infraconstitucionais e federais aventados pela defesa, muito menos afronta à Constituição Federal ou às normas penais ou processuais penais, ou violação alguma a qualquer dispositivo legal ou constitucional, nos termos analisados neste voto. Não há que se falar igualmente em interpretação da lei federal divergente da realizada por outro tribunal. Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24). Ressalto que prequestionamento é direito da parte e, portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se pretende interpor recurso. Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso" (TJSP - Apelação Criminal 1501440-08.2020.8.26.0599, Relator(a): José Vitor Teixeira de Freitas, Comarca: Piracicaba, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 28/02/2022, Data de publicação: 28/02/2022).

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos ao réu não resultariam na sua ressocialização e nem mesmo seriam eficazes para a expiação da culpa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal, pelo que CONDENO o réu JOHNAS MENEGUEL GIMENES ANDRE, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no

valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, notadamente, porque não se alterou a situação fática-jurídica que ensejou a decretação da prisão preventiva. Ademais, a gravidade em concreta da conduta do acusado (ter guardado significativa quantidade de drogas) aliada ao fato de que ele registra antecedente criminal pela prática de crime análogo ensejam a manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a ordem pública e a paz social.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

No tocante aos entorpecentes e objetos (fls. 13) apreendidos, autorizo a destruição.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Bauru, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA